

1518011-32.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARCIO LUCIO FALAVIGNA SAUANDAG

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 22ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/09/2022

... Tudo porque a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes independe da efetiva venda da droga, restando bem delineada nos autos a configuração do delito de tráfico na modalidade de trazer consigo, as demais circunstâncias de fato, em especial o volume, a variedade e o modo de acondicionamento, bem indicando a destinação mercantil.

Sobre o tema: O fato de não terem ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

22ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1518011-32.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1518011-32.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ÁLLIFER DE SOUZA AGAPITO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCIO LUCIO FALAVIGNA SAUANDAG

Vistos.

ÁLLIFER DE SOUZA AGAPITO foi denunciado e se vê processado pela prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 porque, no dia 09 de agosto de 2022, por volta das 12 horas, na Rua Antônio Agostim, altura no numeral 1, Cidade Ademar, nesta cidade e Comarca, trazia consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, 27 (vinte e sete) invólucros de plástico, pesando 184,7g (cento e oitenta e quatro gramas e sete decigramas), contendo maconha, e 38 (trinta e oito) microtubos de plástico, do tipo eppendorf, pesando 12,9g (doze gramas e nove decigramas), contendo cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Recebida a Denúncia, o acusado foi citado, apresentando Resposta à Acusação, seguindo-se a decisão saneadora.

Em audiência foi colhida a prova oral e interrogado o acionado.

Ponderações finais das partes em debates.

Auto de Exibição e Apreensão do Entorpecente, a fls. 06.

Laudo de Constatação, a fls. 09/12.

Laudo de Exame Químico-Toxicológico, a fls. 133/135.

É o relato do quanto necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

De início, bom consignar que descabe ao magistrado impor ao órgão do Ministério Público contratar com o acionado o ANPP, sem amparo na Lei.

Ao oferecer a denúncia a representante Ministerial apresentou seus motivos, negando a oportunidade do ANPP (fls. 66, item 4).

Citado, o acionado apresentou resposta escrita, sede em que silenciou, inclusive, quanto a oportunidade conferida pelo art. 28-A, § 14, do CPP.

Logo, a este momento, descabe qualquer outra providência, máxime porque, consoante coloquei acima, como equidistante das partes, num processo acusatório, descabe ao magistrado interferir na esfera de disposição das partes para ajuste.

Como o magistrado não pode impor a qualquer acionado aceitar um benefício eventualmente proposto pelo órgão de Acusação, não pode, também, impor ao órgão de Acusação oferecer benesse, principalmente da espécie negócio jurídico de natureza extrajudicial.

Muito menos, ainda, substituir-se à figura do Ministério Público.

Sobre o tema, confira-se: A ordem não pode ser concedida. O Acordo de Não Persecução Penal ANPP, instituído no ordenamento jurídico brasileiro pela Lei nº 13.964/19, popularmente conhecido como “Pacote Anticrime”, é prerrogativa do Ministério Público, conforme expressamente dispõe o caput do art. 28-A do Código de Processo Penal (grifos nossos): “Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente”: O mesmo dispositivo processual penal prevê, no § 14: “§ 14. No caso de recusa, por parte do Ministério Público, em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior, na forma do art. 28 deste Código”. A possibilidade de interferência do Judiciário nessa prerrogativa é bastante limitada, prevista nos §§ 4º, 5º, 6º, 7º e 8º, do mesmo art. 28-A do Código de Processo Penal (grifos nossos): “§ 4º Para a homologação do acordo de não persecução penal, será realizada audiência na qual o juiz deverá verificar a sua voluntariedade, por meio da oitiva do investigado na presença do seu defensor, e sua legalidade. § 5º Se o juiz considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições dispostas no acordo de não persecução penal, devolverá os autos ao Ministério Público para que seja reformulada a proposta de acordo, com concordância do investigado e seu defensor. § 6º Homologado judicialmente o acordo de não persecução penal, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para que inicie sua execução perante o juízo de execução penal. § 7º O juiz poderá recusar homologação à proposta que não atender aos requisitos legais ou quando não for realizada a adequação a que se refere o § 5º deste artigo. § 8º Recusada a homologação, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para a análise da necessidade de complementação das investigações ou o oferecimento da denúncia”. Como o Acordo de Não Persecução Penal ANPP foi negado pelas duas instâncias do Ministério Público, não há possibilidade legal de intervenção do Poder Judiciário nesse tema, o qual, volto a frisar, é prerrogativa da Justiça Pública. No mais, não se vislumbra nos autos qualquer constrangimento passível de ser corrigido por meio do remédio heroico. Ante o exposto, pelo meu voto, denego a ordem. (Habeas Corpus Criminal nº 2058982-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. em 18 de maio de 2020, rel. Desembargador CAMILO LÉLLIS); Pois bem. Em prelúdio, como frisado pelo Ministério Público que atua no Juízo a quo, e nos exatos termos da lei, deve o MP entender que o acordo é necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, o que não restou configurado no caso em tela. Conforme lição de Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal, 8ª edição, 2020, Editora Juspodivm, o acordo de não persecução penal, introduzido pela Lei n. 13.964/19 (Pacote Anticrime), cuida de negócio jurídico de natureza extrajudicial, necessariamente homologado pelo juízo competente, celebrado entre o Ministério Público e o autor do fato delituoso (devidamente assistido por seu defensor), o qual confessa formal e

circunstanciadamente a prática o delito, sujeitando-se ao cumprimento de certas condições não privativas de liberdade, em troca do compromisso do parquet de não perseguir judicialmente o caso penal extraído da investigação penal, leia-se, não oferecer denúncia, declarando-se a extinção da punibilidade caso a avença seja integralmente cumprida. Dessa forma, deve-se partir da premissa de que o acordo de não persecução penal deve ser resultante da convergência de vontades (acusado e MP), não podendo se afirmar, indubitavelmente, que se trata de um direito subjetivo do acusado, até porque, se assim fosse, haveria a possibilidade do juízo competente determinar a sua realização de ofício, o que retiraria a sua característica mais essencial, que é o consenso entre os sujeitos envolvidos. Ademais, o legislador previu no art. 28-A, §14, que diante da negativa do Ministério Público em oferecer o referido acordo, pode o magistrado remeter os autos ao i. Procurador Geral de Justiça, nos termos do art. 28 do CPP, o que de fato foi feito nestes autos, conforme podemos verificar às fls. 35/41. No entanto, o digno Procurador Geral de Justiça manteve a posição do Promotor de primeiro grau e insistiu na recusa de oferta do referido acordo. Logo, todas as medidas possíveis ao Poder Judiciário foram tomadas para eventual realização do referido acordo, não sendo possível exigir que o Ministério Público o ofereça após a confirmação da recusa por seu órgão máximo. Com efeito, cabe observar que com o Estatuto Anticrime o nosso ordenamento processual penal deu uma inquestionável guinada no sentido do sistema acusatório puro, colocando o juiz em posição menos interferente no que toca à formulação da acusação. Ou seja, o juiz até pode aplicar o art. 28 do CPP por força do disposto no parágrafo 14 do novo art. 28-A, mas não pode, em sendo mantida a recusa do MP, ir além disso, até porque, se bem observada a nova redação do art. 28 (também por força da Lei 13.964/19 Estatuto Anticrime), o órgão do MP nem mais submete ao juiz a apreciação da sua ordem de arquivamento. Tanto é assim que já há precedentes neste e. Tribunal de Justiça no sentido de que o Poder Judiciário deve se abster de interferir na questão, conforme podemos observar do acórdão proferido pela 15ª Câmara Criminal, no julgamento do habeas corpus 2026314-51.2020.8.26.0000, de relatoria do Exmo. Des. Ricardo Sale Júnior: Acerca do acordo de não persecução penal, trata-se de uma discricionariedade do Ministério Público, eis que o artigo 28 A do Código de Processo Penal dispõe que: Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime (...). Ou seja, trata-se de um dispositivo legal não vinculante, não devendo o Poder Judiciário interferir na obrigatoriedade de sua aplicação. (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2026314-51.2020.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Sale Júnior; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Piracicaba - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 05/04/2020; Data de Registro: 05/04/2020). Acresça-se que o reconhecimento da causa de diminuição de pena no delito de tráfico (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas) impõe na maioria das vezes que haja o processo e dilação probatória para a constatação de todos os seus requisitos, o que, por si só, afastaria o ANPP pois se trata de forma de resolução penal pactuada pré-processual. Enfim, por este voto, DENEGA-SE A ORDEM. (Habeas Corpus Criminal nº 2075422-49.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, 3ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. em 18 de maio de 2020, rel. Desembargador XISTO RANGEL); E circunscrita a competência do Poder Judiciário à análise da legalidade do oferecimento, ou não, da proposta de ANPP, conclui-se que o ato atacado não está maculado de ilegalidade, eis que de modo correto e adequado verificou a formalidade legal do não oferecimento, pelo Ministério Público, da proposta de acordo de não persecução penal que, como visto, está condizente com a disciplina legal acerca do instituto. Não há, por isso, que se reconhecer ilegalidade e nulidade no feito em face da não apresentação de acordo de não persecução penal. Em conclusão, não se observa qualquer ilegalidade ou constrangimento no ato do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorocaba - SP SP. Face ao exposto, DENEGA-SE a ordem. (Habeas Corpus Criminal nº 2062921-63.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, 2ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. em 27 de abril

de 2020, Desembargador KLAUS MARQUELLI ARROYO)

No mesmo sentido: Habeas Corpus Criminal nº 2043590- 95.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. em 22 de abril de 2020, rel. Desembargador NEWTON NEVES; Habeas Corpus Criminal nº 2048237-36.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, 13ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. em 17 de abril de 2020, rel. FRANÇA CARVALHO.

Afastada a questão preliminar, ao mérito, o que verdadeiramente interessa.

A materialidade do crime encontra esteio no Auto de Exibição e Apreensão de fls. 06, Laudo de Constatação de fls. 09/12 e laudo pericial de fls. 133/135, onde se infere que os materiais apreendidos com o acionado, se tratavam, efetivamente, de substâncias entorpecentes, no caso, maconha e cocaína.

A autoria do crime de tráfico imputado ao acionado ecoa da prova produzida, evidenciada sua participação ativa na venda do entorpecente.

Interrogado na fase policial, o acionado confessou a prática do crime pelo qual ora se vê acusado, afirmando que estava no local dos fatos vendendo substâncias entorpecentes e que estava realmente segurando uma bolsa quando foi abordado pelos policiais civis; que recebe uma porcentagem por cada venda (fls. 13).

Em audiência judicial, reiterou a admissão do delito, informando que na data dos fatos estava vendendo drogas para pagar dívida que tinha com os traficantes.

Respalhando a própria confissão do acusado, temos o restante da prova acusatória, de todo séria, encimada nos relatos dos policiais civis responsáveis pela prisão em flagrante do réu.

Ouvidos em Juízo, Nilton Vianna de Carvalho Junior e Cristiano Fernandes de Alcantara apresentaram relatos absolutamente harmônicos, no sentido de que, no dia em questão, estavam na data dos fatos exercendo suas funções, dando continuidade a operação sufoco, quando resolveram ir até um conhecido ponto de tráfico, com uma viatura descaracterizada. Dirigiram-se para a Rua Antônio Agostim, 01, por volta das 12:00hs, e notaram que o acionado estava na via pública. Perceberam que aproximou-se um indivíduo sendo que o acionado pegou alguma coisa de dentro de uma pochete, bolsa na cor preta e entregou para essa pessoa. Em vista desses fatos, em vista dessa fundada suspeita, abordaram o acionado, sendo que a pessoa que estava junto a este e recebeu o objeto saiu em desabalada carreira. Foi possível capturar o acionado e junto ao seu corpo nada de interesse policial foi encontrado. Mas no interior da bolsa preta foi encontrado a quantia de R\$ 12,00, 27 porções de uma substância esverdeada aparentando ser maconha e 38 porções de uma substância branca aparentando ser cocaína. Em função desse fato foi dado voz de prisão pelo crime de tráfico a ALLIFER e conduzido a delegacia para os procedimentos de polícia judiciária.

Neste quadro, dúvida não me paira de que o acionado trazia consigo drogas, consistentes para fins de entrega a consumo de terceiros, 27 (vinte e sete) invólucros de plástico, pesando 184,7g (cento e oitenta e quatro gramas e sete decigramas), contendo maconha, 38 (trinta e oito) microtubos de plástico, do tipo eppendorf, pesando 12,9g (doze gramas e nove decigramas), contendo cocaína, marcadamente destinadas à entrega para o consumo de terceiros, subdivididas em porções individuais, mormente porque não demonstrou condições econômicas para ter tamanha quantidade de drogas unicamente para seu deleite pessoal, sequer comprovando possuir emprego lícito.

Doutro lado, consigno que nada há nos autos a indicar que os policiais, por motivo egoístico ou leviano, tivessem urdido macabra trama, como única pretensão na vida acusar o acionado, sabendo se tratar de pessoa inocente.

No caso em espécie, nenhuma razão séria foi levantada para que se colocasse em dúvida a idoneidade das testemunhas policiais ou gerassem suspeita de especial motivo para prejudicar o acusado.

Além disso, trata-se de réu confesso, circunstância condizente com o restante da prova.

A quantidade de drogas apreendidas, num total de 65 (sessenta e cinco) porções, os tipos de entorpecente encontrados, altamente lesivos, destaca-se a cocaína, o modo de acondicionamento, subdivididos em porções individuais, as circunstâncias do

flagrante, os depoimentos firmes dos policiais que o detiveram, enfim, todo o arcabouço probatório aponta para a conclusão inarredável de que o réu efetivamente praticou a conduta criminosa que lhe é imputada pelo Órgão Ministerial. De tal forma, da prova se extrai que efetivamente o réu praticou a conduta descrita na Denúncia, sendo inviável a pretensão absolutória ou desclassificatória. Com efeito, irrelevante se mostra a não identificação precisa do cliente. Tudo porque a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes independe da efetiva venda da droga, restando bem delineada nos autos a configuração do delito de tráfico na modalidade de trazer consigo, as demais circunstâncias de fato, em especial o volume, a variedade e o modo de acondicionamento, bem indicando a destinação mercantil.

Sobre o tema: O fato de não terem sido flagrados executando atos de mercancia não é suficiente para afastar a responsabilidade pelo tráfico. Afinal, tratando-se de crime cometido em situação de clandestinidade, nem sempre é possível evidenciar a execução efetiva de atos de venda. No mais, sendo o tráfico crime de ação múltipla, configura-se a figura delitiva com a prática de um dos verbos núcleo do tipo penal elencado pelo art. 33 da Lei de Drogas, sendo desnecessária a flagrância de práticas comerciais. Ou seja, o próprio porte e a guarda de substâncias podem subsumir-se à àquela figura delituosa, desde que as circunstâncias do caso evidenciem a destinação (Apelação Criminal nº 0000029-81.2019.8.26.0617, da Comarca de São José dos Campos, 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. em 27 de março de 2020, rel. Desembargador MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI).

Assim, as provas confirmaram os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, o que confere um quadro de certeza quanto aos termos da imputação dada pelo Ministério Público.

Bem firmadas as responsabilidades do réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 passo a mensurar as reprimendas adequadas.

Em primeira fase, as circunstâncias judiciais não se mostram de todo desfavoráveis, motivo pelo qual fixo as penas base do acusado no patamar mínimo previsto em lei. Em segunda fase, presentes as circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, não havendo circunstâncias agravantes. Assim, respeitado o entendimento encerrado na súmula nº 231 do E. Superior Tribunal de Justiça, mantem-se as penas no patamar mínimo.

Em terceira etapa da dosimetria, não há causas de aumento de penas.

Possível, de outro lado, a aplicação do disposto no art. 33, § 4º, da Lei Federal nº 11.343/06, visto que não existem provas de que o réu se dedique ao crime, ou integre organização criminosa.

De tal forma, considerando a quantidade de drogas localizadas em sua posse, bem como os tipos encontrados, altamente lesivos, dentre os quais destaco, cocaína e crack, entendo por bem reduzir as reprimendas do acionado em 1/2, encerrando o cumprimento de pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e pagamento de multa em valor equivalente a 250 (duzentos e cinquenta) dias multa, fixados estes em seu valor unitário mínimo, penas que torno definitivas.

Malgrado em situação parelha, diante do meu entendimento pessoal, o regime fechado seja o mais adequado, acredito que diante das circunstâncias de fato apuradas no processo, tal rigor não merece aplicação, me parecendo suficiente e adequado o regime aberto, máxime diante do arrependimento demonstrado.

Ainda, presentes os pressupostos de Lei, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade mensurada ao acionado por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo lapso da pena corporal imposta, e por uma pena de multa, em valor equivalente a dez dias multa, no mínimo, consoante o artigo 44, § 2º, segunda parte, do Código Penal.

Sobre o tema: Apelação Criminal 1510746-47.2020.8.26.0228; Relator (a): Andrade Sampaio; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 17ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 09/03/2021; Data de Registro: 09/03/2021; Apelação Criminal 1501914-98.2019.8.26.0603; Relator (a): Luiz Fernando Vaggione; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Guararapes - 1ª

Vara; Data do Julgamento: 08/03/2021; Data de Registro: 09/03/2021; Apelação Criminal 0000345-68.2018.8.26.0540; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santo André - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 09/03/2021; Data de Registro: 09/03/2021.

Acredito que mais, seja desnecessário aduzir, posto que nada mais pertine à análise, como forma de dirimir a controvérsia instalada.

Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE o pedido e assim o faço para CONDENAR o réu ÁLLIFER DE SOUZA AGAPITO ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial aberto, e ao pagamento de multa em valor equivalente a 250 (duzentos e cinquenta) dias multa, fixados estes em seu valor unitário mínimo, na forma do art. 43 da Lei nº 11.343/06, por infringência ao disposto nos art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Ainda, presentes os pressupostos de Lei, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade mensurada ao acionado por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo lapso da pena corporal imposta, e por uma pena de multa, em valor equivalente a dez dias multa, no mínimo, consoante o artigo 44, § 2º, segunda parte, do Código Penal

Tendo em conta a pena aplicada e o seu regime inicial de desconto, defiro eventual apelo do réu em liberdade.

Expeça-se Alvará de soltura clausulado.

Transitada esta em julgado, que seja o nome do réu lançado no rol dos culpados, transferindo-se o valor apreendido nos autos, a fls. 06 (comprovante a fls. 23/25), ao FUNAD, posto se tratar de evidente produto do comércio espúrio de entorpecentes. Arcará o condenado, com o pagamento das custas do processo, nos termos do art. 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/03.

Sentença dada e publicada em audiência, saindo os presentes cientes e intimados. P.R.I.C.

São Paulo, 26 de setembro de 2022.

Marcio Lucio Falavigna Sauandag
Juiz de Direito Titular I da 22ª Vara Criminal Central

Assinatura digital, nos termos do art. 1º, § 2º, inciso III, alínea "a", da Lei Federal nº 11.419/06